

次の教授と学生の【会話】は、各種書面の証拠能力に関する議論である。【会話】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、aが正しいものには1を、bが正しいものには2を選びなさい。

【会 話】

教授：刑事訴訟法第321条第3項の「検証の結果を記載した書面」に、捜査機関が任意捜査として行う実況見分の結果を記載した書面（以下「実況見分調書」という。）が含まれるかについて、あなたはどのように考えますか。

学生：私は、実況見分調書も含まれると考えます。検証と実況見分は、①（a. いずれも弁護人の立会権が明文で認められており b. いずれも客観的・技術的性質を有しており）虚偽が入る余地が少ないと考えるからです。

教授：次に、私人が作成した書面について、刑事訴訟法第321条第3項の準用又は類推が認められるかについて、あなたはどのように考えますか。

学生：私は、認められると考えます。ただし、私人が作成した書面全般に準用又は類推を認めるべきではなく、私は、②（a. 捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認められるときは b. 特別の学識経験に基づいた報告であれば）準用又は類推を認めてよいと考えています。

教授：火災原因の調査を行う会社に勤める元消防士で、通算約20年間火災原因の調査・判定に携わった経験のある私人が、燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面の証拠能力について、判例はどのような判断を示しましたか。

学生：判例は、③（a. 刑事訴訟法第321条第3項の準用により証拠能力を有する b. 刑事訴訟法第321条第3項の準用は否定されるが、同条第4項の準用により証拠能力を有する）旨の判断を示しました。

教授：では、医師が作成する診断書について、判例は、どの条文を根拠に証拠能力を認めていますか。

学生：④（a. 刑事訴訟法第321条第3項 b. 刑事訴訟法第321条第4項）を根拠としています。

教授：また、判例によれば、酒酔い鑑識カードの化学判定欄及び被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する各記載は、いずれも刑事訴訟法第321条第3項により証拠能力が認められるとされていますが、更に警察官が被疑者に質問を行い、これに対する被疑者の応答を記載した部分について、判例はどのように述べていますか。

学生：⑤（a. 化学判定欄等と一体となって刑事訴訟法第321条第3項により証拠能力が認められる b. 警察官作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号により証拠能力が認められる）と述べています。

No246	各種書面の証拠能力					正答率 40%
予備H28-22	正解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 2	オ 2

①について

①には、教授の「刑事訴訟法第321条第3項の『検証の結果を記載した書面』に、捜査機関が任意捜査として行う実況見分の結果を記載した書面（以下「実況見分調書」という。）が含まれるか」という問いに対する学生の「実況見分調書も含まれる」との答えの理由づけが入る。最判昭35.9.8（百選A38事件）は、「刑訴321条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、検証と実況見分はいずれも客観的・技術的性質を有して虚偽を造出する余地が少なく、両者は、捜査の過程において捜査機関の手により実施され、その態様と調書作成の業務的性格に異なるところはなく、令状の有無が正確性に違いを生じさせることはないから、両者の証拠能力要件に差をつける実質的理由はないということを挙げている。したがって、①には「b. いずれも客観的・技術的性質を有しており」が入る。

②について

②には、教授の「私人が作成した書面について、刑事訴訟法第321条第3項の準用又は類推が認められるかについて、あなたはどのように考えますか」という問いに対して、これを肯定する立場に立つ学生の答えが入る。321条3項の準用・類推適用がどの範囲にまで認められるかという問題について、捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認められるときは、同項の準用を考慮する余地があると解する説がある。したがって、②には「a. 捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認められるときは」が入る。

③について

③には、教授の「火災原因の調査を行う会社に勤める元消防士で、通算約20年間火災原因の調査・判定に携わった経験のある私人が、燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面の証拠能力について、判例はどのような判断を示しましたか」との問いに対する学生の答えが入る。上述の判例は、最決平20.8.27（百選83事件）である。判例は、「本件報告書抄本〔注：「燃焼実験報告書」と題する書面の抄本〕は、同法321条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有する」としている。その理由として、判例は、321条3項「所定の書面の作成主体は『検察官、検察事務官又は司法警察職員』とされているのであり、かかる規定の文言及びその趣旨に照らすならば、本件報告書抄本のよう私人作成の書面に同項を準用することはできない」ということ、及び、本件報告書抄本の「作成者は、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有するものであり、本件報告書抄本は、同人が、かかる学識経験に基づいて燃焼実験を行い、その考察結果を報告したものであって、かつ、その作成の真正についても立証されていると認められる」ということを挙げている。したがって、③には「b. 刑事訴訟法第321条第3項の準用は否定されるが、同条第4項の準用により証拠能力を有する」が入る。

④について

④には、教授の「医師が作成する診断書について、判例は、どの条文を根拠に証拠能力を認めていますか」との問いに対する学生の答えが入る。最判昭32.7.25は、「医師の作成した診断書には正規の鑑定人の作成した書面に関する刑訴法第321条第4項が準用される」との原判決の判示が正当であるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、専門的な知識経験により事物の法則を認識し、これに関連する意見を形成するという意味では、鑑定書も診断書も共通点を有すること、医師が公務所に提出すべき診断書に虚偽の内容を記載すれば刑事制裁（刑法160条）のある点でも、

鑑定人の場合と類似していること、日常的に患者を診断する医師に対し、記憶に基づき口頭で報告を求めるよりも、書面で報告を求めるほうが正確であることなどを挙げている。したがって、④には「b. 刑事訴訟法第321条第4項」が入る。

⑤について

⑤には、教授の「判例によれば、酒酔い鑑識カードの化学判定欄及び被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する各記載は、いずれも刑事訴訟法第321条第3項により証拠能力が認められるとされていますが、更に警察官が被疑者に質問を行い、これに対する被疑者の応答を記載した部分について、判例はどのように述べていますか」という問いに対する学生の答えが入る。上述の判例は、最判昭47.6.2である。判例は「本件『鑑識カード』のうち被疑者との問答の記載のある欄は……刑訴法321条1項3号の書面にあたる」としている。その理由として、判例は、「本件『鑑識カード』のうち被疑者との問答の記載のある欄は、同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、必ずしも検証の結果を記載したものということとはできず……同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして、刑訴法321条1項3号の書面にあたる」ということを挙げている。したがって、⑤には「b. 警察官作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号により証拠能力が認められる」が入る。